

非典型与典型案件:术语、成因及其关系

周 贇*

内容提要 “非典型案件”是当前法治实践以及法学研究中的热点话题,它通常指的是那些适用法律存在争议的案件。从逻辑上讲,单纯的事实认定存疑由于在法律上的处置实际上是清楚、确定的,因而并不必然衍生非典型案件。导致非典型案件产生的间接原因涉及法律、事实及法律-事实关系等多个方面,但直接原因仅在于当事人及其法律职业服务者的选择;并且也正因如此,非典型案件与典型案件无法截然二分,相反,它们几乎总是可以相互转换,这意味着当前许多专门针对非典型案件的制度安排或实践活动存在着根本的缺陷,因而必须予以废止或重构。

关键词 疑难案件 非典型案件 事实与规范

一、问题的缘起

区别对待简易案件与普通案件、疑难案件(复杂案件)、重大案件是当前我国相关制度安排的一个基本精神和明显倾向,与此相对应,理论界对于简易案件与疑难案件的二分命题也几乎一边倒地给予支持,在有案可稽的文献中,我们找不到有任何作者试图对两者的二分命题作哪怕是一点质疑,更多的是把它当作一个当然成立的命题来对待。

疑难案件或简易案件二分命题并非仅仅涉及两者的二分本身,从更深层次上讲,第一,它至少还涉及如下问题:如果二者真的截然二分,那么,如何解释有些所谓的简单案件经过审理后被认定为疑难案件进而进入相应的程序?相对应地,又如何解释某些看上去疑难的案件最终审理发现其实并不疑难?这一对问题背后的理论问题是哪些因素、又怎样决定了一个案件属于简单案件或疑难案件?更进一步讲,二分命题的立论基础是什么?换言之,我们可以根据哪些理由把两者的二分当作当然成立的命题?显然,我们有义务对这些问题给出清晰、有力的回答。第二,它直接关乎法学理论的基本格局。如果两者确乎可以二分,那么,就应该存在两种关于司法决策的法学理论:一种仅

* 厦门大学法学院教授,法学博士。本文系2015年福建省社科基金项目“错案应对机制研究”(项目批准号:2015221017)的阶段性成果。

满足于揭示、解释简单案件的解决过程,而另一种则旨在解决疑难案件问题。然而,迄今为止,即便是那些明确视二分命题为当然的论者,也并没有试图构建关于这一主题的理论。这从另一个角度也表明,如果两者其实并不能二分,则可以说一种只能解释简单案件的理论(如典型的法条主义理论^①)或疑难案件的理论(有意思的是,当前没有一种理论宣称仅仅针对疑难案件)从根本上来讲就是有问题的。

当然,对二分命题及它的如上子问题作出详尽探究不仅仅具有理论的必要性,还紧密关联着当下中国的相应实践。譬如,《中华人民共和国民事诉讼法》以及《中华人民共和国刑事诉讼法》都专门规定了对部分案件适用“简易程序”。前者第142条规定:“基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件,适用本章规定”。后者第208条规定:“基层人民法院管辖的案件,符合下列条件的,可以适用简易程序审判:(一)案件事实清楚、证据充分的;(二)被告人承认自己所犯罪行,对指控的犯罪事实没有异议的;(三)被告人对适用简易程序没有异议的。人民检察院在提起公诉的时候,可以建议人民法院适用简易程序”。另一方面,应当主要是基于审级以及司法社会效益等方面的考量,我国几大诉讼法都规定了凡属“本辖区内重大、复杂的案件”(或类似表述,如“是全省性的重大刑事案件”)的,哪怕相应该辖区的法院层级分别是中级、高级、甚至最高人民法院,也应当由该法院行使一审管辖权(《行政诉讼法》第14条、《民事诉讼法》第19-21条以及《刑事诉讼法》第20-24条)。可以看到,此种规定的基本立法精神正是区别对待简易案件(适用简易程序的案件^②)和普通案件^③、复杂案件(疑难案件)、重大案件,而这显然又建立在两类案件二分的命题基础上。当然,反映类似精神主旨的制度安排或司法实践并不仅仅限于这些立法,还包括几乎当下中国各级人民法院(以及检察院、公安机关)专门针对复杂疑难案件设计的种种制度、举措,典型者如《刑事诉讼法》第180条关于人民法院审判委员会对“疑难、复

① 也称“形式主义理论”,对应的英文表述可以是 legal formalist 或 conventionalism。相关讨论,参见周赞:《一百步与五十步:法条主义与其批评者的差别》,载《江汉论坛》2014年第2期。

② 必须明确的是,从逻辑上讲,案情“重大”的案情也可能是“简易案件”,但却不适用简易程序。因此,从逻辑、并且仅仅是从逻辑上讲,“简易案件”并不能等同于“适用简易程序的案件”,但应该说在经验中,“简易案件”几乎总是“适用简易程序的案件”之下位概念(后者还包括诉讼各造“对适用简易程序没有异议的案件”——这类案件有可能、但也往往仅仅是逻辑上有可能是疑难复杂案件)。从这一角度可以说,至少在经验中,重大案件实际上是疑难案件的一种。

③ 仅从我国相关立法的术语来看,与“适用简易程序的案件”相对的是“普通案件”,然而从对“适用简易程序的案件”之界定来看,所谓普通案件——即除“适用简易程序的案件”以外的案件——其实也正是本文语境中的“疑难案件”(非典型案件)。

感谢厦门大学法学院副教授陆而启博士在阅批本文时指出的这一问题。

杂、重大”案件进行“讨论决定”的制度^④,如有些地方设立的“疑难案件专家听证制度”^⑤,又如有些地方设立的“疑难案件清理制度”^⑥,再如有些地方设立的“疑难案件诉前会议机制”^⑦。此处或许可以提及的、与之相关的另一现象是,有些科研院所还专门设立所谓“疑难案件研究中心”或“重大疑难案件研究中心”^⑧。

显然,面对如此丰富的制度、实践及相应现象,我们没有理由继续无视疑难案件与简单案件的二分命题及其背后的理论意蕴。而这也正是本文的立意所在,它旨在表明,第一,疑难案件与简单案件二分命题并不能成立。第二,当前部分关于司法决策的理论存在根本上的缺陷。第三,前述正在实践的许多制度建立在并不牢靠的基础上因而必须予以调适。

二、术语的选择:“非典型案件”,而非“疑难案件”

细心的读者可能已经发现,本文的主题是“非典型案件”,但迄今为止一直讨论的却是“疑难案件”(以及“简易案件”或“简单案件”),这颇有文不对题的意味。另外,就当下汉语语境而言,一方面,“疑难案件”显然更符合当前的用语习惯(使用频度明显高于“非典型案件”),而“非典型案件”则有生造新词的嫌疑;与此相对应,另一方面,硬性引入“非典型案例”这一术语也可能会造成不必要的用语纷扰。那么,为何笔者明知存在这些风险却仍然选择作这样的安排?

这首先因为“疑难案件”这一术语在当下的汉语表述中已经被用“滥”了,以至于我们很难确定它到底指的是怎样的案件。以前文提及的当前各种关于疑难案件的制度安

④ 该条的具体措辞是“合议庭开庭审理并且评议后,应当作出判决。对于疑难、复杂、重大的案件,合议庭认为难以作出决定的,由合议庭提请院长决定提交审判委员会讨论决定。审判委员会的决定,合议庭应当执行”。

此处或有必要提及的是,该规定似乎明显与《人民法院组织法》中对审判委员会权能的规定相左,后者第10条规定,“各级人民法院设立审判委员会,实行民主集中制。审判委员会的任务是总结审判经验,讨论重大的或者疑难的案件和其他有关审判工作的问题”——其中的具体措辞是“讨论”(没有“决定”);另外《行政诉讼法》以及《民事诉讼法》中并没有类似《刑事诉讼法》的规定。当然,从实践中看,《刑事诉讼法》的规定似乎“一览众山小”而把所有这另三种法律(尽管他们其实处于同一层级——如果《人民法院组织法》不属于更高层级的法律、也即宪法部门法的话)“比下去”了,因为审委会几乎一律扮演的是法院系统内部的最高司法决策机构(“最高审判组织”)之角色(详见最高人民法院2010年1月11日颁发的《关于改革和完善人民法院审判委员会制度的实施意见》)。

⑤ 如河南省就有类似的制度安排,详可参见《18名法学大家受聘河南法律专家委员,把脉疑难案件》,载“新华网·河南频道”,http://www.ha.xinhuanet.com/hnxw/2013-08/29/c_117135052.htm,最后访问日期:2015年3月29日(以下网络文献,最后访问日期都是2015年3月29日)。

⑥ 这是四川省曾推行过的做法,详可参见《四川高院推进民商事疑难案件审理》,《人民法院报》2011年9月26日。

⑦ 详可参见《天津市红桥区人民检察院积极筹划“疑难案件诉前会议机制”确保案件质量》,载“人民网·天津视窗”,<http://www.022net.com/2014/1-15/504145252289550.html>。

⑧ 有案可稽的相应报道,详可见《重大疑难案件研究中心在湖南大学成立》(2014年1月),载“湖南大学新闻网”,<http://news.hnu.edu.cn/mthd/2014-01-17/1124.html>;“中国政法大学疑难案件研究中心成立于1996年”,载该中心官方网站,<http://www.lawcase-center.com/intro.asp>。

另一个值得注意的、紧密关联着本文主题和当下中国法治实践的倾向是,似乎有一部分学者或官员开始有意无意地把当前推行的案例指导制度中的“案例”限定在疑难案件的范畴上。

排为例,不难发现它们中有些用“疑难案件”指称单纯的事实鉴定、认证存疑的案件,有些指向的却是法律适用的疑难案件,有些则指向两者都有争议的案件。但无论是如上三种情形的哪一种,都被统称为“疑难案件”,相对应的另一类案件则通通被称为“简易案件”。以2012年修订的《刑事诉讼法》为例,它事实上就分别包含着如上三种意义上的“疑难案件”。这可以从该法对简易程序中的“简易案件”(与疑难案件相对的案件)作了这样两个方面的界定看出:一方面,案件事实明确、争议不大;另一方面,适用法律方面也没有很大的争议。具体规定是第208条第一、二项规定。“(一)案件事实清楚、证据充分的”,“(二)被告人承认自己所犯罪行,对指控的犯罪事实没有异议的”。显然,如上两项规定中第一项涉及的是事实认定方面无疑问;第二项涉及的则是适用规范无争议,所谓“指控的犯罪事实”表明的正是此层意思:“犯罪事实”的措辞本身就已经表明它是法律适用的结果,因为一项事实是否构成犯罪事实以及构成哪一种犯罪事实必须以相应法律规定为依据才能作出判断。换言之,根据这些条文,则可以认为与此相对的“疑难案件”包括“事实不清楚”或“适用法律有异议”以及两者兼具的案件。^⑨

另外尚须提及的是,在当前日常的、非专业的表述中,“疑难案件”尤其是其缩略词“疑案”一般被用来表述单纯的“事实认定存疑的案件”——这尤其体现在各种文学影视作品或大众媒体的报道中。而实际上,站在司法的或者专业的角度看,“疑难案件”所指称的本不应是单纯事实认定存疑的案件^⑩,而只能用来指称那些适用法律有争议的案件。那么,是否笔者认为并不存在事实认定存疑的案件?或者说,事实认定存疑的案件并不构成疑难案件?对此,笔者的回答是:当然存在单纯的事实认定存疑的案件,但从根本上讲,单纯事实认定存疑的案件并不构成法律实施意义上的疑难案件。

不妨举例说明。譬如,在某杀人案中,侦查机关最终发现并确认张三有作案动机以及其它作案条件,某案的案发现场所有线索亦指向张三,但其实最关键的是这样一个线

⑨ 国内理论界似乎也多持此种认识,所谓“尽管没有疑难案件的精确定义,但对于如何界定疑难案件,依然存在两个基本共识。第一个基本共识是要区分法律规则上的疑难案件与案件事实上的疑难案件。所谓法律规则上的疑难案件是指因法律规则存有缺陷而使案件的处理存有争议的案件;而案件事实上的疑难案件则是指案件事实扑朔迷离,真相难以查清的案件。这一区分相当重要,不能将两者相混淆”。参见季涛:《论疑难案件的界定标准》,载《浙江社会科学》2004年第5期;类似的文献还可参见刘忠理:《当前疑难案件的特点、成因及预审对策》,载《公安大学学报》1992年第3期;沈仲衡:《疑难案件的法律解释》,载《河北师范大学学报(哲学社会科学版)》2004年第5期;徐继强:《法哲学视野中的疑难案件》,载《华东政法大学学报》2008年第1期;孙海波:《疑难案件的语义争议及成因初探》,载《研究生法学》2011年第6期;高军、张今文:《“疑难案件”之法理蕴含》,载《广州大学学报(社会科学版)》2012年第11期;等等。

⑩ 在当前国内的相应讨论中,由于刑事案件的“强势”(更符合传统的“法即刑”观念,以及更容易引起媒体的关注),在舆论或文学作品中,人们似乎主要用“疑难案件”或“疑案”来指称“疑难刑事案件”,并且往往是用来指称“侦办过程中事实认定存疑的刑事案件”。这一倾向甚至明显地表现于专业的学术讨论中:2014年4月初(本文的初稿时间),笔者在“中国知网”的“期刊”领域,以“疑难案件”为“篇名”进行检索,共发现152篇相关文献,其中只有36篇不是仅仅从事实认定存疑、也即不是仅仅从侦办角度考察“疑难案件”,另有1篇《〈诗经〉疑难词语辨析》(作者杨合鸣,《诗经研究丛刊》2002年第1期)明显不属于本文关注的范畴,另外所有的115篇(比例高达75.7%)都仅仅从刑事侦查角度讨论疑难案件问题。如果把检索领域扩大到“报纸期刊”,这个比例应当会更大,换言之,这个倾向应当会更加明显。

索,一位自拍者的自拍视频显示张三在案发时出现在现场。此时,第一,如果法律正好规定“私人自拍影像”具有证明力,则该案就可能证据充分、事实认定没有疑问。反之,第二,如果法律规定“私人自拍影像”不能作为证据采信,或仅仅是法律没有清楚规定私人自拍影像能否作为证据,则该案就可能“变得”证据不充分进而成为事实认定存疑的案件。另外,第三,本案当然也可能由于单纯的证据不足、而非证据因不具有合法性而成为事实认定存疑的案件。显然,第一、二两种情形表面上涉及的是对事实的认定,但实质上却是“根据既有法律,相关证据材料能否被采信为证据存在争议”这样一个法律问题,因此第二种情形中所谓“事实认定存疑”的实质是法律适用存疑(第一种情形则不构成疑难案件)。至于第三种情形,可以肯定它将意味着巨大的“疑难”,但这种疑难只构成侦查机关的侦查技术角度上的疑难,对审判结论、甚至对侦查机关最终的侦查结论来说,前述第三种情形在法律上并不构成疑难,因为它的法律答案是肯定、明确的:根据疑罪从无原则,被怀疑(相对侦查结论)或被指控(相对审判结论)的罪名不成立。

总之,如果一个案件真的仅仅存在事实认定方面的疑问,并且这些疑问不能或没有转化为法律适用方面的疑问,那么,它可能仍然是日常意义上或最多只是侦查机关技术角度的“疑难案件”或“疑案”,但却根本不构成司法决策过程中的疑难案件,因为单纯的事实疑难案件,其实在法律上讲具有明确而清楚的结论:在刑事法律领域是明确且肯定的“疑罪从无”^①,在民商事及其他领域则是当事人的主张不被支持。这一方面表明,当前立法表述中被用来与“适用简易程序的案件”相对称的“普通案件”,实际上也是“适用法律有争议”的案件,也即实际上属于疑难案件的范畴;而当前立法表述中经常用到的“疑难”或“疑难复杂”案件,则似乎主要是一种修饰性、程度性甚至可以说文学化的概念,因为它们同样不过是“适用法律有争议的案件”进而与“普通案件”之间并没有清楚的界限。另一方面,这也正解释了何以哈特(H. L. A. Hart)认定,只是由于法律规则具有“开放结构”(open texture)属性,或者更准确讲是因为用来表述法律规则的术语总是具有意义中心和意义边缘,才会形成普通案件与疑难案件的区分,前者处于法律规则的意义中心,后者处于法律的意义边缘——在哈特讨论疑难案件问题时,压根就没有提及单纯的事实认定存疑的案件。^②

因此,本文之所以倾向于使用“非典型案件”而非“疑难案件”,并不是基于术语或语词本身所具有的差别,而是因为当前的大众舆论以及虽不严肃却体量巨大的学术作品中,“疑难案件”这一术语已经被用滥了,因而如果继续使用这一术语可能会导致如下问题:首先,偏狭地以为“疑难案件”指的是单纯事实认定存疑的那一部分案件;或者,其次,它还可能导致这样一种误会:“疑难案件”包括事实认定存疑的案件、法律适用存

① 当然,在有些情形中,当事实认定存疑并非涉及有无、而是事实的具体样态时(如一个行为到底是“抢夺”还是“抢劫”),则可能会导致适用法律上的争议,进而成为疑难案件。但很显然,在这种情形中,直接决定该案成为非典型案件的关键仍然是“适用法律有争议”,而非单纯的事实认定有争议本身。

② See Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1961, P. 121-132;持这种将疑难案件限于法律适用疑难案件观点的另一典型是德沃金(Ronald Dworkin),相关论说请见下文。

疑的案件以及两者皆有争议的案件三大种类。而实际上正如前文已经表明的,至少在法律实施领域以及在法学(而非物证鉴定学科)领域,“疑难案件”应该用来指称那些适用法律有争议的案件^⑬;最后,如果继续使用“疑难案件”这一术语,再考虑到当下立法表达中惯于把“适用简易程序的案件”与“普通案件”相对称这一因素,则很容易产生这样两个显然很难作答的问题:“普通案件”与“疑难案件”的关系是什么?“适用简易程序的案件”与“疑难案件”的关系又是什么?总之,笔者之所以倾向于不采用“疑难案件”而选定“非典型案件”,恰恰是因为前者由于自始没有得到严肃、清楚地界定因而被用得过多并最终消解或至少动摇了它作为一个具有特定内涵之专业术语存在的基础;相反,如果用“非典型案件”这一术语来专门指称法律适用有争议的案件,则既可以同样对译于英语世界中常用的相关词汇“hard case”、“borderline case”、“untypical case”,也可以揭示出如上这些术语以及“疑难案件”、“复杂案件”以及与“适用简易程序的案件”相对的“普通案件”所包含的共同内涵,还不容易引起国内汉语读者以及论者的如上可能误会或困难。

换言之,尽管引入“非典型案件”这一术语看上去似乎有违“如无必要、勿增实体”的“奥卡姆剃刀原则”(Ockham's Razor),并可能引来其它质疑^⑭,但在笔者看来,这其实是“不得已”的选择:如果大家对“疑难案件”这一术语的认识达成了一致或至少大体上的一致,则确实没有必要引入“非典型案件”这一术语;相反,则为了更清楚地说明问题,也为了在司法实践中更准确地运用相关术语,就只能接受实体的多重化(繁琐化),即引入新术语。

那么,应当如何界定非典型案件?在学界既有的讨论中,德沃金的界定可能是最具知名度和代表性的之一。德沃金在构建“作为整体的法律”理论时曾提出“疑难案件”(hard case)这一概念,他认为,所谓 hard case 即“在法律规范体系中,没有清晰的规则(norm)可以明确规范到的案子”^⑮。当然,有必要明确的是,在德沃金那儿,所谓没有明确规则可循的案子并非没有法律(law)可循的案件,因为在德沃金看来,法律除了由显

⑬ 此处或许还有必要提及拉兹(Joseph Raz)的如下发现:有些有明文法律可依循的案子可能比没有明确法律可依循的案件疑难得多,所谓“根据法律解决复杂的税务问题可能比根据道德原则解决自然正义问题更为困难”(参见[英]拉兹:《法律的权威》,朱峰译,法律出版社2005年版,第159页)。拉兹此论揭示出,至少仅仅从术语本身的角度看,“疑难案件”其实更多地强调的仅仅是“复杂、困难”而“非典型案件”则可能更多地强调的是“适用法律有争议”,尽管“适用法律有争议”与“复杂、困难”可能有关联,但毫无疑问它们并不出于同一逻辑层面、更无法相互替代。如果这一判断能够成立,那么,它当然亦可以当作是本文不使用“疑难案件”这一术语的一个有力理由。

⑭ 譬如,本文一审外审专家就曾在其审稿意见中质疑,“如果可以如作者所言‘非典型案件’更法律化,而疑难案件等更文学化、生活化,这种替代究竟是为了方便法律适用还是方便法学教义呢?法律是否应该脱离生活而变成抽象的概念?”

⑮ R. Dworkin, *Hard Cases*, in *Harvard Law Review*, Vol. 88 (1975); R. Dworkin, *A Matter of Principle*, Massachusetts: Cambridge University Press, 1985, P. 13; 在另外的场合,他则采取另一种说法来表述这同样的一种界定:“在现代法律制度中,典型的疑案案件之所以产生,不是因为受到争议的法规中缺乏什么内容,而是因为法规中的法规是以一种不确定的声音说出的”。[美]德沃金:《原则问题》,张国清译,江苏人民出版社2012年版,第9页;类似的表述,还可见该书第89页。

在的规则以外、还由潜在的原则(principle)以及政策(policy)构成;德沃金并认为,在很大程度上,其实恰恰是原则和政策、或者说单单原则使得所有的法律构成因素可能组成一个前后连贯的整体。因此,即便出现了没有明确规则可循的案子,也决不意味着法律本身存在一个漏洞,毋宁说,它更多地意味着的是法官的无能:一个能干的法官一定可以在规则之外找到某些既存原则来裁判疑难案件。^⑩

在很大程度上,本文所谓“非典型案例”其实也就是德沃金所谓之“hard case”,因为非典型案例最典型、或者说最本质的特征就是在现存法律体系中,没有无争议的法律条文可以用来作为裁判依据^⑪。但可以看到,两者确实存在某些不同,本文意义上的非典型案例强调的是没有明确法条可以遵循,而法条既可被用来设定规则,也可被用来设定原则。相对而言,德沃金似乎在界定“原则”时没有很清楚地界分“明确体现在法律条文中的原则”和“没有在法律条文中予以明确的原则”;另外,由于德沃金非常强调隐藏在规范背后的原则,并且他自己也承认,“我们不能设计出一个公式,用来检验如果使一条原则成为法律原则需要多少制度上的支持,需要哪一种制度上的支持,也不能用来确定它的量度和尺度”,因而“原则是有争议的,原则是有重要分量(差)的,原则是数不清的,并且,它们的转移和变化是如此迅速,以至于当我们还没列举到一半,这一清单的开关就已经过时了”^⑫。这至少意味着,德沃金所谓的原则本身很可能成为一个争点,而本文的“法条”则可以实证、因而也不容易引起争论;再考虑到有时候人们其实很难区分法律条文中的“原则”与“规则”,因为二者的区别本就不那么清楚的——事实上,很多人在区分原则和规则时往往用的也是前者比后者的“抽象性更强”诸如此类的程度性说法,因此,将“法条”而非“规则”、“原则”作为非典型案例的界定关键词至少从清晰程度角度看更加可取。

另外尚须回应的一个问题是:本文对非典型案例(hard cases)的界定,与前文提及的哈特之界定——学界另一经典界定——又有何区别?简而言之,本文的界定更为明确、直接,具有更强的可实证、可操作意味;而哈特的界定更为间接、含混,因而也更不容易把握。^⑬

^⑩ 关于“作为整体的法律”观,可参见 R. Dworkin, *Is Law a System of Rules?*, in Ronald Dworkin ed., *The Philosophy of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1977, P. 38-65;更为详细的展开,参见《法律帝国》一书,尤其是该书第六章、第七章,参见 R. Dworkin, *Law's Empire*, Massachusetts: Cambridge University Press, 1986;中译本参见[美]德沃金:《法律帝国》,李常青译,中国大百科全书出版社1996年版。

^⑪ 相对地,典型案件就是存在无争议的法律条文可以用来作为裁判依据的案件。

^⑫ R. Dworkin, *A Matter of Principle*, Massachusetts: Cambridge University Press, 1985, P. 13.

^⑬ 必须明确,此处关注的主要不是本文对“hard cases”的界定与既有经典界定有何不同,而是为解决该术语在现代汉语中译为“疑难案件”还是“非典型案例”何者更妥这一问题。

三、(非)典型案件的成因:间接的与直接的

乍看起来,似乎当笔者将“非典型案件”定义为“没有无争议法条可以适用、也即适用法律有争议的案件”时,它的产生原因就已然得到了清楚的呈现:因为该定义表明,没有无争议的法条可适用,也即法律规定的內容不能无争议地涵摄(subsumption)当前案件事实,即非典型案件产生的原因。譬如法律规定“水果必须经过统一检验方可入境”,而案件事实则是一批西红柿——西红柿到底属于水果还是蔬菜、准确讲到底是否属于此处的“水果”可能有争议——是否需要统一检验,此时就可能成为一个适用法律有争议的非典型案件。

当然,我们还可以进一步分析哪些因素可导致事实与规范的错位。在逻辑上可从两个相互关联的方面着手。一是法律本身的原因,如哈特所谓的空缺结构的存在,使得总有些事实处于模糊、可争议的境地;又如法律本身出现了用语冲突,进而导致适用过程中的争议。二是事实本身具有非典型性,也就是说,行为人作出了一种此前成熟术语无法进行无争议涵摄的行为,这又可细分为两种:(1)行为本身具有明显的“创新性”,譬如“许霆案”中许霆的行为^①,就可能无法无争议地纳入到“盗窃”、“侵占”或“不当得利”等成熟术语之中;(2)行为本身并无明显“创新”,但由于社会价值观、文化的演变,对行为的评价发生了转型,譬如婚外恋或婚外性行为是否总是构成对《民法通则》第6条规定的“公序良俗原则”的违反,在不同时期就可能得到不同评价,20年前或更早时期,这些行为几无疑问是典型的“伤风败俗”;20年后或更晚时期,或许这些行为将得到完全不同的评价;而在处于这两极的“今天”,对这些行为的评价则可能有争议,进而必定导致部分案件在是否适用该条文问题上产生争议。^②

就笔者所见,论者在分析非典型案件的产生原因时,大体都是这样一种思路:对可能导致涵摄争议的各种法律因素、事实因素予以罗列、揭示。^③应当肯定的是,此种讨论有助于较为清楚地揭示、解释非典型案件,但另一方面也存在如下两种弊端:

首先,此种思路无法就如下疑问给出一个符合逻辑的解释、回答:如果非典型案件产生的原因是法律不能无争议地涵摄案件事实,那么,若我们能够证成法律恒无法无争

^① 关于“许霆案”案情始末及其终审判决,参见《广东省广州市中级人民法院刑事判决书》[(2007)穗中法刑二初字第196号]。

^② 最典型的大概就是当年被许多媒体冠以“全国第一起‘二奶’遗产继承案”的“泸州争产案”,关于该案始末及其判决,参见《四川省泸州市纳溪区人民法院民事判决书(2001)纳民初字第556号》。

^③ 相关典型文献,如刘星:《略论法律适用中的疑难案件》,载《中山大学学报(社会科学版)》1993年第3期;国内类似但说服力尚不及该文的文献如孙海波:《案件为何疑难?——疑难案件的成因再探》,载《兰州学刊》2012年第11期;孙海波:《疑难案件的语义争议及成因初探》,载《研究生法学》2011年第6期;沈仲衡:《疑难案件的法律解释》,载《河北师范大学学报(哲学社会科学版)》2004年第5期;等。国外学者走的似乎也大体是这个路数,相关典型论者如德沃金、哈特,参见 Dworkin, *Hard Cases*, in *Harvard Law Review*, Vol. 88 (1975); Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1961, P. 121-132;等。

议地涵摄案件事实,则是否意味着所有案件都是非典型案件?换言之,如果我们能够证成法律恒无法无争议地涵摄案件事实,则是否意味着不存在典型案件?再换言之,典型案件何以可能?

当然,这一疑问本身能否成立取决于我们能否证成“法律恒无法无争议地涵摄案件事实”这一命题。显然,如果可以证成“法律恒无法涵摄案件事实”,则当然也就意味着“法律恒无法无争议地涵摄案件事实”。那么,法律与案件事实之间是否存在逻辑涵摄与被涵摄关系?波斯纳(R. Posner)在讨论法律适用问题时曾敏锐地意识到,“逻辑就像数学一样,它探讨的是概念间的关系而不是概念与事实的对应关系。而法律制度不能不关心经验真理的问题”^②——尽管波斯纳没有明说,但他的这个判断实际上已经指出:在类似数学这样的领域,严格的涵摄关系能够存在,但在法律这样一种经验世界中,规范与事实之间的涵摄关系其实并不存在。那么,为什么规范与事实之间不可能存在严格的涵摄关系?这主要是因为规范由概念组成,而概念只能存在于人的理念世界,我们经验到的只是其载体,我们不可能经验到概念本身,而只能通过思维去把握;事实却存在于经验世界,它是可经验的。申言之,规范与事实本就根本不同,因此,不同质的两个范畴怎么可能形成严格的涵摄关系?那么,为什么在很多案件尤其在典型案件中,人们并没有这么明显地感觉到规范与事实的这种“根本不同”,以至于案件结论大前提与小前提之间似乎真的存在严格的涵摄关系?这主要是因为作为小前提的“事实”已经不再是单纯的经验世界的事实,而是经过加工、被赋予意义的事实,如从“张三用刀砍了李四一刀”这个事实变成了“张三实施了故意伤害行为”,其中的“故意伤害”就是法官赋予前一事实以某种意义之后的结果。很明显,“意义”一如“规范”,也只能存在于理念世界,而这至少保证了作为案件结论小前提的事实与规范两者的同质性,并进而使得大、小前提之间能够形成一种更为严格的涵摄关系。当然,即便是经过法官的这种对小前提的“偷偷”置换,我们也充其量只能说小前提(具有某种意义的事实)与大前提(法律规范)之间只是存在大致的涵摄关系,而无法达致像数学领域那样的涵摄程度。之所以作出这一判断,是因为法官赋予某种事实的意义并不与规范之间构成严格的上下位概念关系,而往往只是接近或主要方面存在相应关系而已。譬如,法官确立了这样一个规范,“虐杀人者应当判处死刑立即执行”,而当下案件的事实(已经被赋予法律意义)“苏格拉底虐杀了数人”,应该说大体上当下案件事实与审判规范之间存在一种涵摄关系,但这种关系并不纯然也不严格:一方面,苏格拉底可能是个“半疯子”,他到底是否构成适格的主体几乎完全取决于法官的即时判断;另一方面,苏格拉底的虐杀可能建立在防卫的基础上,但这防卫又显然大大地过当,这意味着“防卫”是否构成量刑因素也几乎完全取决于法官的即时判断;再一方面,苏格拉底的所谓虐杀之具体表现是用刀疯狂砍杀数十刀,它到底是否构成“虐杀”的标准,也几乎完全取决于法官的即时判断;……在这里,不妨借用一位论者的如下论断来归纳此处对“法律规范恒无法涵摄案件事实”这

② [美]波斯纳:《法理学问题》,苏力译,中国政法大学出版社2002年版,第69页。

一命题的证成:“逻辑涵摄是法学借重科学主义方法论用以塑造司法裁判确定性的法律适用技术范式,然而法律适用的要旨在于理解规范和事实的意义,这不同于传统上科学是以观察、测量为基本方法的。推理过程的空洞性、大小前提的不确定性等因素决定了演绎推理不可能是法律适用的核心技术,从而逻辑涵摄无力担当法律适用技术范式的重任。它只是司法裁判的最后一步,是对裁判结论确定性的正当化包装。”^②

其次,此种进路将导致对非典型案件产生之直接原因的遮蔽,进而错把“影响因素”当作原因,换句话说,错把间接原因当作直接原因。尽管“影响因素”与“原因”在语文上可能无法清楚界定——事实上,《现代汉语词典》对“原因”的解释正是“造成某种结果或引起另一件事情发生的条件”,而对“因素”的解释则是“决定事物成败的原因或条件”^③。但在本文中,笔者将那些必须通过其它因素为中介方能导致某种结果产生的因素称为“影响因素”,而将那些中介其他因素、也即直接导致某种结果产生的因素称为“原因”。为了表述的方便,当然也为了避免引起更多的误会或争议,笔者将前者称为“间接原因”,将后者称为“直接原因”。那么,何以本文认定既有讨论揭示的“原因”其实只是间接原因而非直接原因?这主要基于如下考量:正如前述,由于本质上任何法律规范都恒无法涵摄某种单纯的事实,这意味着如果法律或事实本身所具备的某些因素就足以导致非典型案件,则逻辑上的结论就应当是所有案件都为非典型案件;这进一步意味着,一定存在某个或某些因素作为中介,并且正是该因素在中介过程中的筛选作用,使得有些案件成为了典型案件而另外一些案件成为了非典型案件。换个角度讲,考虑到法律规范恒无法涵摄案件事实,则如果抽离中介因素的筛选,我们实际上也就无法解释何以有些案件是典型案件而有些是非典型案件,更无法解释何以有些案件可以游移于典型案件与非典型案件两个阵营之间(即下文将要论述的“非典型案件的典型化”与“典型案件的非典型化”)。那么,是何种因素中介了前述法律以及事实本身所具有的某些特质进而构成了非典型案件产生的直接原因?简言之,即诉讼双造(准确讲是为其提供法律建议的专业人士)的专业选择行为。具体说来,只要诉讼中的某一方愿意并且专业上足够高明,就可以通过自己的专业说理,突出当下案件中导致法律适用有争议的法律因素或事实因素,进而使当下案件“变成”(become^④)非典型案件;相对应地,任何一方亦可通过自身的专业说理,突出当下案件中更具共识意味的法律或事实因素,进而使当下案件变成典型案件^⑤。

也就是说,法律以及事实本身的某些特质,只是诉讼双造用以支撑己方选择以及结

② 这是一篇学术论文的“内容摘要”,在正文中,作者对之作出了详细且有说服力的分析、证成。参见朱良好:《法律适用逻辑涵摄技术范式的反思》,载《商丘师范学院学报》2009年第5期。

③ 分别参见“中国社会科学院语言研究所词典编辑室”编:《现代汉语词典》,商务印书馆2005年版,第1620、1676页。

④ 此处更准确的表述应该是加达默尔(Hans G. Gadamer)的“转化”(Verwandlung)。加达默尔对“转化”的界定是:“指某物一下子和整个地成了其他的东西,而这其他的作为转化成的东西则成了该物的真正的存在,相对应这种真正的存在,该物原先的存在就不再是存在的了。”([德]加达默尔:《诠释学 I:真理与方法》,洪汉鼎译,商务印书馆2007年版,第157页。)

⑤ 具体例证请见下文“对直接原因的进一步阐明:基于两者二分命题的崩塌”部分。

论的理由、基础而已,它们本身并不会直接导致一个案件成为非典型案件或典型案件,真正的直接原因只是诉讼各造的专业选择:如果把当下案件变成非典型案件有助于自身选择的实现,他就突出这些特质;如果把当下案件变成典型案件有助于自身选择的实现,则他突出法律与事实的另外一些特质。可以说,正是由于诉讼双造的选择才是非典型案件产生的直接原因这一点,一方面解释了为何一个案件可以同时是典型案件和非典型案件,进而解释了为何有些案件被“办成”了典型案件而另外一些成了非典型案件——这些现象的实质是:有一方当事人对于案件的加工结论(典型案件或非典型案件)提出了更高明的专业说理,而并非这些案件本身属于非典型或典型案件;另一方面也解释了何以有些专业技能高明的法律人可以使“铁案”改判,或为何有些律师“出场费”高昂却仍然门庭若市而另一些“出场费”低廉却门可罗雀——因为一个高明的法律人几乎总是可以通过突出当下案件中的某些特质而使得案件变成典型案件或非典型案件,进而最大程度且总是合法地维护己方当事人的利益。后一点套用在法官身上,则呼应、解释了如下现象:“一个‘聪明’的法官总是能从现行法律中找到合理的解释以使自己的判决正当化。仅就公布的判决书表面研究,很难找出这位法官有什么不当动机,一般都要借助一些外部的线索。”^②

四、对直接原因的进一步阐明:基于二分命题的崩塌

在英语世界的法律实践中,人们之所以特别关注非典型案件(hard cases)问题,可能源自一个法谚“Hard cases make bad law”以及一些著名案件的司法实践。^③ 在理论界,则似乎可以把“非典型案件”当作关键词的做法归之于哈特的研究,因为正是哈特第一次尝试着揭示出了非典型案件产生的法律语言学基础,并且引发了哈特与德沃金、德沃金与富勒(Lon Fuller)、德沃金与拉兹之间持久的学术论战。同样是哈特,第一次在非典型案件与典型案件之间划了一条线,自那以后不论是哈特的“论敌”德沃金,还是富勒、马默(Andrei Marmor)、拉兹、卢瑟福(Kermit Roosevelt III),抑或是国内的学者,似乎都认定非典型案件与典型案件是一对截然二分的范畴(所不同者仅仅在于对非典型案件的产生原因或应对策略之认知),也就是说,在经验中,有些案件是并且只是典型案件,另外一些案件则是并且只是非典型案件。

在笔者看来,这种把非典型案件与典型案件当作经验中可以截然二分的范畴之认识,正是人们在讨论非典型案件时除了偏爱使用“疑难案件”且自觉不自觉地泛化其指称范围、把间接原因当直接原因这一谬误外,另一个常见的错误倾向——当然,这是一

^② 这是德萧维兹(Alan M. Dershowitz)对美国著名的“马丁·T. 马顿法官枉法裁判案”(马顿是美国20世纪20-30年代著名且长期被认为杰出的法官,因为某个意外事件而被发现在他的职业生涯中几乎所有案件都被其刻意作出了给其行贿方有利的判决,这些判决在该意外事件产生前,从没有人、也没有司法同僚怀疑过其合法性)的“总评”。参见[美]德萧维兹:《大法官的偏见》,廖明等译,五南图书出版公司2005年版,第112-113页。

^③ 参见徐继强:《法哲学视野中的疑难案件》,载《华东政法大学学报》2008年第1期。

个尚待证成的判断。

从逻辑上讲,如果能够揭示出在经验世界中非典型案件与典型案件本就可以相互转化,也就是说,经验中不存在一个或一类案件只可能是典型案件或只可能是非典型案件,那么,关于典型案件与非典型案件二分对立的观点当然就无法成立。更进一步讲,那些仅仅满足于说明、解析典型案件的法学理论也一定同样不可取。相对应地,所有那些建基于两者二分基础上的制度设计当然也有问题。那么,典型案件与非典型案件是否是一对相互转化的范畴?换言之,经验世界中是否存在纯粹的典型案件(或非典型案件)?实际上,当笔者在前文中得出如下结论时就已经对这个问题给出了否定的回答:对于经验世界中的任何一个案件而言,只要法律人足够高明并且又有足够的意愿,他就几乎总是可以把一个案件加工为典型案件或非典型案件。接下来让我们分别来证成“典型案件的非典型化”以及“非典型案件的典型化”两个命题:

首先,关于典型案件转化为非典型案件。人们似乎普遍认为,经验中的大部分、甚至绝大部分法律案件都是典型案件,所谓“法律史中的大多数案件,甚至大多数宪法案件都不是疑难案件”,或“一个类似的问题在习惯法中是放在疑难案件(hard cases)标题下进行讨论的。社会学家必须首先看到,这种案件在数量上只占法院所要裁决的全部案件中很小一部分”^⑨。这种通行的看法似乎也可以在如下现象中得到验证:绝大部分法律事务不会成为诉讼案件,并且相当一部分诉讼案件仅仅通过一审、甚至诸如“简易程序”等渠道就可得到妥善解决。然而,事实却并非如此。我们不妨来看看如下这样一个可能会被视为典型的典型案件之案件:

某集市外有一老太太戴着红袖章负责给来集市购物者看自行车。具体操作方法是:该老太太在集市门口圈出一块空地,并用橡皮筋将该空地围了起来;来客只需要将自行车放入该橡皮筋圈定的范围之内,然后缴纳5毛钱人民币即可。某次,有一顾客购物后发现其价值数千元的电动自行车不见了。遂以急于履行保管义务为由,要求该老太太赔偿相应的损失。^⑩

从表面上看,失主关于被告人急于履行保管义务的主张事实清楚,因为即便是被告人也承认失主确实交了5毛钱并且其自行车置于橡皮圈内后丢失了;同时法律依据也很充分,因为按照《合同法》(1999年)第369条第一款“保管人应当妥善保管保管物”以及第374条“保管期间,因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的,保管人应当承担赔偿责任,但保管是无偿的,保管人证明自己没有重大过失的,不承担赔偿责任”

⑨ 参见[美]德沃金:《自由的法:对美国宪法的道德解读》,刘丽君译,上海人民出版社2001年版,第14页;[德]卢曼(Niklas Luhmann):《社会的法律》,郑伊倩译,人民出版社2009年版,第164页。在笔者所见的几乎所有相关文献中,作者几乎都持有类似认识或判断。

⑩ 本案例直接出处是周贇主编:《法理学教程》,对外经济贸易出版社2007年版,第223页。须说明的是,此类案件在现实生活中非常普遍,或至少是并不少见,此处为避免不必要的麻烦而作了简化处理。如近些年被热炒的超市“保管箱”在内的各种纠纷,相关典型报道及分析,参见汤征宇、陈亚男:《车辆保管合同与场地租赁合同之辨》,载《人民司法》2011年第4期。

之规定,被告人显然要承担全部的损失责任。换言之,这是一个典型的典型案件。但实际上却并非如此,或者说并非必然如此,因为作为被告人的老太太方,完全可能也可以提出这样一种主张:她与原告签订的其实是场地租赁合同而非自行车保管合同,因此,自行车的被盗并不应由她承担相应损失。冷静而中立地评价,则很容易发现由于被告方这一主张的提出,本案实际上变成了一个具有巨大争议的非典型案件,因为,它到底适用哪些法律规定、法律条文变得有争议了。当然,完全有理由相信,尽管就笔者当下的思考而言,似乎除了原告关于“保管合同”以及被告关于“场地租赁合同”的主张外,本案没有了其它的可能,但这并不意味着真的就没有了别的可能。

其实,何尝只有本案可能从一个典型案件转变为非典型案件?可以说,经验中几乎所有被定性为“典型案件”、“简易案件”的案例,其实只是暂时没有遇到挑战的案件而已。换言之,它们之所以被认定为典型案件,是因为涉案的各方以及关注该案的旁观者或者没有意愿、或者没有能力提出类似前述案例中被告人那样的异议又或者是两者兼有而导致正好达成了法律适用方面的一致看法。显然,所谓“正好”意味着一个案件之所以被认定为“典型案件”只是一种偶然性的结论,它并不意味着该案实际上不可能有别的答案或不可能产生争议。再换言之,没有任何案件“先天”或“注定”只可能是典型案件,毋宁说是各种偶然因素的存在——其中最可能也是最主要的是正好没人提出具有至少大致相同说服力的异议——而导致双方当事人正好无争议。在这里,或有必要强调指出的一点是,只是诉讼各造而非法官的选择才应该成为案件非典型化的直接原因,因为法官作为纠纷解决的中立介入者,理应无权无中生有地、也即在各造主张以外引发争议。如果一个案件在诉讼各造那里就法律适用问题的整体或局部没有争议,那么,法官就不必也不应仅仅因为自己认为有争议而把其认定为非典型案件(进而转入到相应特定程序);换个角度讲,如果法官认为是典型案件,但诉讼各造却实实在在地就法律适用方面产生了争议,那么该案就当然地成为了非典型案件。^②这也意味着,当前各种关于疑难案件(非典型案件)的法律规定把非典型案件的认定权交给法官或法院是一种不符合司法中立、被动面貌因而极不妥当的制度安排。或者说,如果一个法官或法院具有强烈地主导典型案件非典型化的意愿,那么,此时我们完全有理由怀疑该法官或法院的职业操守以及其采取这种做法之动机的纯洁性。从另外一个角度看,对法官来讲,最重要的本也不应是判定一个案件是“典型案件”还是“非典型案件”,而是当一个案件双方有争议时,该如何在各种争议结论中识别出更具有可接受性的那种主张。

其次,关于非典型案件的典型化。所谓非典型案件的典型化,说的是通过某种特定

^② 这一判断或许在私法领域不致引起争议,但在公法尤其是刑法领域则可能会有不同认知。因为有人可能会认为,在刑法领域,即便检察院(控诉方,相当于原告)与被告(犯罪嫌疑人)之间达成了某种共识(无争议),但法院认为该共识无法排除所有合理怀疑时,也不应在刑法上承认该共识,换言之,此时该案仍应以非典型案件对待。笔者以为,这是一种似是而非的观点,如果这一观点成立,实际上颠覆了法官(或法院)的被动性、中立性这一区别于其它国家公权的本质属性,并因此消解了司法审判权作为一种独特国家公权存在的根基。事实上,从另一个角度讲,只有承认法院必须谨守被动性、中立性,我们才能理解盛行于西方的辩诉交易(或控辩交易)制度何以具有可接受性。

的代理或辩护或司法决策策略,使一个本来颇具争议的案件变成具有相对清楚且无争议案件的过程或现象。同样,不妨先从一个案例出发来探讨这一转化:

23岁的李某在两年多时间里花费上万元的现金,在一个游戏里积累和购买了几十种虚拟“生化武器”。但2003年2月,他的所有武器装备却都被游戏运营商收回了,于是李某致电游戏运营商A公司,要求返还他的“生化武器”,A公司则以种种理由拒绝。最终,李某以游戏运营商侵犯了他的私人财产为由把该公司告上法庭。^③

这个案子或者说这类案件之所以被认为是非典型案件,是因为人们面对它们时往往把审议的焦点集中在这样一系列问题上:网络世界的虚拟武器是否属于民法上的“物”?如果不算,那么,本案还能适用以“物”为立法基础的相关民事法律条文吗?如果算,它是有体物还是无体物?如果是有体物,那么,它的“体”在哪儿?如果是无体物,那么,为什么我们明明可以从屏幕上看到?相应地,如果算作民法上的“物”,那么,它是否属于民法上的“个人财产”?如果属于,应当如何估价以便进一步核算原告的损失以及赔(补)偿金额?等等。部分论者在讨论本案时,甚至拿出韩国以及我国香港等地区的立法和司法经验进行说理,进而得出“我国针对网络‘虚拟财产’法律规定还较为滞后”的判断,并提出“只有出台有效的法律,才能更好保护日渐增多的‘虚拟财产’,形成对网络游戏产业的有效监管”的吁求。^④

可以看到,如果我们将本案的焦点定于如上这些争议,再考虑到我国既有法律确实没有明确的相关规定,则确实有充分的理由认为该案是一个典型的非典型案件。但如果我们换作如下思路来分析这一案例,则很可能发现这一本来具有争议因而很难短期内作出判决的案件,其实可以是一个很快给出确切答案的典型案件。譬如法官跳出如上争议的窠臼,而径直依据《民法通则》(1986年)第4条“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则”之规定,则可以很容易地得出“A公司应当返还李某虚拟武器”的判决结论。具体的决策逻辑及理由是:第一,双方都认同的是,A公司与李某就虚拟武器签订的是买卖合同,既然如此,则只要该买卖合同之标的具有合法资格,就可以认为随着李某的交款和A公司的“武器”交付行为,这些武器的所有权已经发生了转移;第二,结合《民法通则》诚实信用这一帝王条款的要求,则A公司当然没有资格也没有法律上的其它理由在未经李某许可的情况下收回那些所有权已经转移到李某手中的虚拟武器。可以看到,这种判决思路最大的好处是,它回避了“虚拟武器是否是民法上的物”以及前述相关的一系列争议问题,并进而提出了一个在法律上很容易达成共识的结论。这意味着,至少就乍看上去是典型的非典型案件的本案而言,只要换一种合适

^③ 这同样根据一个真实案例改编。参见《国内首例虚拟财产失窃案昨日一审宣判》,载《北京青年报》2003年12月19日。

^④ 关于本案的讨论,参见刘军霞:《首例虚拟财产纠纷案引发的法律思考——兼论虚拟财产的保护》,载《河北法学》2004年第1期;关于“虚拟财产”本身的讨论,可参见林旭霞、张冬梅:《论网络游戏中虚拟财产权利的法律属性》,载《中国法学》2005年第3期;陈旭琴、戈壁泉:《论网络虚拟财产的法律属性》,载《浙江学刊》2004年第5期;等等。

的思路,它完全可以“变成”一个典型案件。如果再考虑到法院的职责是为有争议的案件及时提出一个法律上讲得通的结论,而非“狗拿耗子多管闲事”地去涉足自己并不擅长、更无必要的理论争议领域。那么,至少对法院而言,类似本案这种非典型案件就不仅仅是“可以”转变成典型案件,而是“应该”转变成典型案件,因为一个案件越是典型,法院得出的相应结论就越容易被各方所接受。更进一步讲,如果本案作为一个非典型案件可以被典型化,则当然有充分的理由认为,其它所有非典型案件都可以通过决策思路的变换而达到典型化的效果。

至此可以说,在经验生活中并不存在“天生如此”的“非典型案件”或“典型案件”,毋宁说,这两种案件只是一种逻辑上的对立。在现实生活中,由于法律不可避免所具有的滞后性以及用以表述法律的文字所必定具有的意义模糊性和多变性,也由于作为案件结论小前提的事实本身所具有的开放性^⑤,因此只要有人(除法官以外的人)有足够的意愿并有足够的法律职业能力或专业想象力,就完全可以、甚至有时应该破除“非典型案件”与“典型案件”间的藩篱。概言之,对于真正高明的法律人而言,一个案件到底是典型案件或非典型案件是一个始终两可的问题,这也正是马丁·斯通(Martin Stone)、斯蒂芬·波顿(Steven J. Burton)等人作出如下判断的真义所在:所谓“清晰案件(典型案件)是由于解释力量的结果”^⑥,更具体地说,是当事人、法律人的选择而非“规则或案件本身自动选择并组合各种因素进而设定诉讼策略才决定了疑难案件(非典型案件)的存在。”^⑦这也意味着,对于某一个案到底是典型案件还是非典型案件的判断只是一个说服力、可接受性强弱而非对错的问题。

虽然如上结论看起来多少有点儿“所欲胜者因胜,所欲罪因罪”^⑧的意味,但或许这才是法律世界的真相;更进一步讲,似乎也只有这种判断才能因应具有如下特质的当前社会之内在要求:“也许可以肯定地认为,这种对确定的、确实的必然性的逃避,这种含糊和不确定的倾向,正反映了我们时代的危机状况;或者恰好相反:这些理论同今天的科学相一致,表现了人们对不断改变自己的生活模式和认知模式采取开放态度的积极能力,表现了人们有效地努力推进自己的选择余地和自己的新境界的进程的积极能力。”^⑨

换个角度看,正因为非典型案件与典型案件存在的是这样一种“暧昧”、“不清”而非截然二分之关系,才能呼应、解释如下现象:在立法体系本身几无变更的前提下,某些特定案件在某些特定时刻(如第一个类似案件发生时)被认为是典型的非典型案件(或相反),但在其它时候则可能会被视为典型案件(或相反)。以“许霆案”为例:当该案刚

⑤ 有关这一点,详情请见下文“对间接原因的进一步阐明:基于对事实、法律及其相互关系的考察”。

⑥ [美]斯通:《聚焦法律:法律解释不是什么》,载[美]马默(Andrei Marmor)主编:《法律与解释:法哲学论文集》,张卓明、徐宗立等译,法律出版社2006年版,第57页。

⑦ S. J. Burton, *An Introduction to Law and Legal Reasoning*, Boston: Little Brown and Co., 1985, P. 97.

⑧ 这是子产等人用来描述、批判邓析的说辞,参见《吕氏春秋·审应览第六·离谓》。

⑨ [意]艾柯(Umberto Eco):《开放的作品》,刘儒庭译,新星出版社2010年版,第23页。

刚发生时,被广泛当作典型的非典型案例对待(否则不至于引起如此多的讨论),但随着该案判决的作出以及最终被广泛接受(或许经验层面是一种“不得不接受”,但即便如此也毕竟是“接受”)。不难想见,随着这种“接受”的形成,此后若再发生类似案件,法院显然会倾向于径直当作无争议的典型案例——比照许霆案——进行判决。换言之,当我们用更长的长镜头或更广的广角镜去观测判决经验的历史长河时,如果不确立典型案例与非典型案例无法截然二分的观念,就注定无法解释如上现象。

至此,笔者尝试着证成了经验中没有非典型案例与典型案例的截然二分格局。这里还有必要予以明确的是,这种证成并不妨碍它们在理论上、逻辑上是一对具有重要意义且可以截然二分的范畴。换言之,它们其实正是一对韦伯(Max Webber)所谓的“理想类型”(ideal type)^④:在经验中永远找不到严格的对应物,但却是颇有价值的一种分析问题、解决问题的必要概念工具。为何这种概念工具如此必要,韦伯给出了一个颇具辩证意味的解释,“在现实中,严格的区分往往是不可能的,不过正因如此,明确的概念就更加必要。”^⑤

五、对间接原因的进一步阐明： 基于对事实、法律及其关系的考察

接下来的一个问题是,非典型案例与典型案例相互转化的间接原因是什么?换言之,当事人或其它关心案件结论的人通过其意愿和能力中介了哪些因素,才使得典型案例与非典型案例之间可以发生“转型”?再换言之,是哪些因素的什么特质使得人们的主观能动性有了发挥的空间?总体而言,可以从如下三个方面来对这一组问题进行回答。也就是说,当事人或任何其它关心案件结论的人可以凭借如下几个因素中的一个或几个来完成对典型案例的非典型化(或非典型案例的典型化):

第一,由于从生活事实到作为裁判结论小前提的事实,即被赋予了法律意义的赤裸裸之案件事实^⑥的转化是一个充盈着主观性的过程,因此当事人可以通过发挥事实认定过程中的主观能动性进而实现典型与非典型案例的转化。从逻辑上讲,由于所谓非典型案例就是指具有清晰条文可以调整的案件,因此如果一个案件的事实本身就是模糊的、不确定的,那么无论法律规范是否清楚、确定,都必定无法清楚地涵摄、调整它,进而也就当然地属于非典型案例。那么,案件事实可能无争议吗?回答是否定的。因为所

④ 韦伯关于“理想类型”的介绍与界定,参见[德]韦伯:《社会科学方法论》,杨富斌译,华夏出版社1999年版,第36-56页。

⑤ [德]韦伯:《经济与社会》(上卷),林荣远译,商务印书馆1997年版,第240页。

⑥ 在下文中,为了以示区别,笔者将赤裸裸的关于案件的生活事实称为“案件事实”(如“张三砍了李四一刀”),而将被赋予法律意义的、也即作为最终裁判结论小前提的事实(如“张三用砍李四一刀的方式实施了故意伤害”)称为“法律事实”。笔者此处不拟介入学界当前关于“法律事实”这一术语及其概念本身的争议,而仅仅是为了区别如上两种意义上的事实而引入这一术语。

谓案件事实,并不是单纯的、上帝所知道的那个已经发生因而我们再也无法严格重现的生活事实本身,而是经由法官根据案件片断并结合自己的经验、运用自己的想象力而回构出来的事实。在这里,所谓“片断”是一个大于但包括案件侦办过程中的“证据”之概念,也就是说,所有的证据都属于此处所谓的片断,但法官用以回构案件事实的原材料显然并不止于证据,至少还包括生活常识、逻辑常理、案件发生的背景(如白天还是晚上就将很大程度上影响回构的结论,但一般不认为“白天”或“晚上”是证据)等外围因素。而所谓“回构”,则说的是案件片断并不会自动组合成为一个逻辑相对完整的事实,而必得由法官根据自己的经验并充分发挥想象力才得以可能——正因如此,才解释了何以即便面对同样的案件片断也很可能得出不同的案件事实结论。换言之,对于法官而言,案件事实亦注定是主观加工(我国诉讼法中的“认定”一个词语某种程度上暗合了这一点)的,因而注定是可错的,即无法恒确定或恒清楚的产物。

当然,关联着事实问题,对法官而言或许更明显地需要发挥其主观性的一点是,法官还必须赋予其回构出来的案件事实以特定的法律意义。由于犯罪分子不会依法犯罪(当然,其他案件也不会严格依法发生),因此,案件事实的法律意义往往存在各种可能的答案——甚至可以断定,“意义”一词本身就意味着主观性、可争辩性或可错性,而不可能由惟一确定的、正确的或像部分媒体所说的“铁”一样的意义(所谓“铁案”)^③。

申言之,作为案件结论小前提的法律事实实际上是当下办案人员(如法官)发挥主观能动性并通过如下步骤加工而成:首先,办案人员依据法律收集案件片断、证据;其次,办案人员根据这些片断、证据并依凭常理、逻辑回构、想象出某种事实;最后,办案人员依据特定法条赋予该事实一种特定的意义。不难想见,无论是哪一步,都注定是一个充盈着主观性、选择性的过程,因此,只要一个法律人有足够的意愿并有足够的职业能力,就可以在如上三步中的任意一步或几步中“翻手是云、覆手是雨”。

退一步讲,即便在某些案件中,由于取证的足够充分或其它因素的存在,使得当事人很难对事实进行加工,也并不意味着他就没有了别的依凭来使一个案件“转型”。这是因为第二,作为判定一个案例是否典型之依据的法律条文本身是不确定的、流变的且模糊的。关于法律尤其是成文的法典法,迄今为止最重大误会之一是:它们白纸黑字地写在那儿、镌刻在那儿,其意义当然是明晰、确定、清楚的。为什么说这是一个误会?因为所有的法律都以人类语言符号为载体进行表述,而人类语言以及人类语言符号所具有的一个本质特征正在于其意义的多变性、模糊性,所谓“人类语言的标志在于,它不像动物的表达标志那样僵硬,而是保持着可变性。这种可变性不光表现在人类有许多种语言,还在于人能用相同的语言和相同的语句表达不同的事物,或者用不同的语句表达同一事物”^④,”真正的人类符号并不体现在它的一律性上,而是体现在它的多面性上。

^③ 关于作为案件结论小前提之事实所具有的这种开放性,笔者曾专门撰文详细讨论。参见周赞:《开放的事实——并及我国〈刑事诉讼法〉的修订问题》,载《现代法学》2013年第1期。

^④ [德]加达默尔(Hans G. Gadamer):《哲学解释学》,夏镇平等译,上海译文出版社1994年版,第60页。

它不是僵硬呆板而是灵活多变的。”^⑤那么,为何人类语言符号本质上会呈现出这种变动性?这主要是因为构成语言的基本单位——语词——都总是具有哈特所谓之“意义中心”和“意义边缘”,因而从一种历史的眼光看该语词的意义总是变动不羁的,并且即便在特定的语境中也只可能其意义中心相对确定,而意义边缘仍然是不确定的。^⑥对用以表述立法的语言符号来说,或许尤其当其面对本就可能具有争议的案件事实时会显现出其不确定性。譬如某单位门口树一规定“外来机动车辆不得入内”,本来“机动车辆”本身看起来比较确定,但当它面对诸如警车、展览馆的标本车、玩具机动车等事实时就会显得明显模糊起来。考虑到“犯罪分子(一般)不会依法犯罪”(或其它案件不会依法发生),则基本可以说,法律条文的意义一定是模糊的、多变的。而这,当然亦是有关人士发挥其主观能动性进而促使案件“转型”的重要抓手。

更进一步讲,第三,即便涉案各方对作为小前提意义上的事实本身以及作为大前提的规范都没有争议,也并不意味着一个案件就只可能是典型案件。因为即便面对同样的大前提、同样的小前提,一个人也完全可能得出不同的结论。最典型的相关例证是“王海案”^⑦,这一案件的实质是对如下问题的争议:知假买假者是否属于消费者?在这个案件中,原被告双方对于王海知假买假的事实没有争议,对应当适用《消费者权益保护法》第2条“消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务,其权益受本法保护;本法未作规定的,受其他有关法律、法规保护”之规定也没有争议,有争议的仅仅是:王海方认定“知假买假”属于“消费”,而商家方认为“知假买假”不属于“消费”。须说明的是,当涉讼各方对大小前提本身没有争议时,并不意味着有关各方只有本案当中的这种“是或否”的空间,即面对同样的大、小前提,各方完全有可能作出肯定或否定两种截然不同的回答;还至少存在“多或少”的空间,即各方面对相同的大、小前提时,有时完全可以甚至应当在作为大前提之条文所规定的幅度范围内作出处置幅度的裁量。换言之,即便各方对大、小前提本身没有争议,也决不意味着案件就成为了只有唯一确定答案的典型案件。

如上,笔者从三个方面对典型案例可能转化为非典型案例进行了证成,这一证成可能很容易导致如下推断:经验世界中原来反而只存在非典型案例,所谓典型案件都不过是“凑巧”、“恰好”各方无争议而已。对于这一可能的推断以及潜伏其后的质疑,此处

^⑤ [德]卡西尔(Ernst Cassirer):《人论》,甘阳译,上海译文出版社1985年版,第47页。

^⑥ 当然,如果不考虑“立法语言”这一前提,语言符号的意义之所以总是流变的,也因为特定语境中特定语言的使用者往往具有某种个性化的“意向”因而导致特定的语言符号往往具有多样化的意义——这也正是当年维特根斯坦(L. Wittgenstein)认定“一个词的意义就是它在语言中的使用(用法)”([德]维特根斯坦:《哲学研究》,李步楼译,商务印书馆1996年版,第31页)的原因所在。本文正文讨论立法语言的意义流变性问题时之所以不把这个因素考虑进来,是因为立法语言作为一种以普适为面向的语言,相对而言,其运用者(立法者)会、也理应尽最大可能克制自己的个性化意向。当然,必须明确的是,这并不是说立法者的个性化意向在立法语言中就完全得不到体现。

^⑦ 关于“王海案”及其分析,参见王利明:《也谈王海现象与惩罚性赔偿的运用》,载《判解研究》,人民法院出版社2000年版(总第1辑);杨立新:《“王海现象”的民法思考——论消费者权益保护中的惩罚性赔偿金》,载《河北法学》1997年第5期;等等。

不妨预先作出如下回应:如上证成固然表明所有的典型案件都可以转化为非典型案件,但其实它们同时也可以看作是对如下命题的证成:任何非典型案件都可以通过如上三个方面中的一个或几个方面而被“加工”、“转化”为典型案件。申言之,如上对事实、法律以及两者关系不确定性的分析和证成,并不只可用来证成“所有典型案件都可以之为抓手而转化为非典型案件”或“任何非典型案件可以之为抓手转化为典型案件”,毋宁说它更为根本的目的或效果在于揭示,由于如上三个间接原因的存在,典型-非典型案件间的相互转化有了依凭。当然,这也再次呼应了前文关于典型-非典型案件无法截然二分的判断。

六、结论及建议

在本文中,笔者尝试系统探析非典型案件的各个重要面向,提出了这样几个主张:第一,非典型案件是那些适用法律条文存在争议的案件,所谓“事实争议”的案件,如果不能落脚到适用法律的争议,则并不构成非典型案件(或疑难案件);与此相关,第二,由于“疑难案件”在当下语言中已经形成了某种可能无法短期内改变的使用习惯(可用来分别指称单纯事实认定存疑、法律适用存疑或两者皆存疑的案件),并且与另外一些常用术语(如“普通案件”)也无法形成一种圆洽的逻辑关系,因此,为了以示区别,当然也为了因应如上第一个判断,本文提出不妨以“非典型案件”来指称各种法律适用存疑的案件;第三,应当注意区分导致非典型案件产生的间接原因和直接原因,这不仅仅是基于术语以及逻辑准确性的考量,更重要的是因为唯有如此,我们才能真正揭示出非典型案件产生的原因,并对相关的一些社会现象作出有说服力的解释;当然也因为这进一步呼应着,第四,非典型案件与典型案件之间并不存在二分格局,毋宁说它们几乎总是可以相互转换,而转换之可能性程度直接取决于各方当事人(实质上是具有法律专业技能的代理人、检察官或法官)是否有足够的意愿、能力并恰好掌握了足够的资源(如新出现的某项可能导致定性变化的证据);与此同时,第五,虽然经验中非典型案件与典型案件并没有截然二分的界限,但从逻辑上又确实可以对二者作出清楚的界分;最后,第六,诉讼各造之所以有可能通过自己的主观努力而使得一个案件游移于非典型案件与典型案件的边缘,主要是因为司法过程中的事实、法律以及对两者关系的认定,根本上具有开放性、可错性。

基于此,笔者认为可分别针对当前法学研究以及法治实践提出如下建议:

第一,用“疑难案件”、“疑案”等术语来指称那些单纯事实认定有争议、困难的案件——可以预见,它将主要体现在刑事侦查活动以及非专业的表述中(因为对负责审判的法院而言,所有的事实问题归根结底都一定是法律问题);而用“非典型案件”指称那些已经引发出法律适用争议、困难的案件;至于两方面都存疑的案件,则分别用两个术语指称。至于已经被广泛用在针对司法的立法表述中的“普通案件”、“疑难案件”、“复杂案件”甚至“重大案件”,其实质都属于非典型案件,它们相互间并无实质区别,也可

以说这些立法措辞具有一定的随意性。

第二,任何一种法学理论都不应满足于揭示、解释典型案件的解决过程,而必须能够同时解释非典型案件的解决,因为一种只能解释典型案件的理论一定不是一种具有普适性的理论,相反,由于能解释非典型案件的理论往往可以解释典型案件因而普适性更强,而普适性正是理论之所以为理论的一种重要内在秉性。在这个意义上,如下这种对学界偏好关注非典型案件的批评可能根本上无法成立:“(部分法学教授们)总是讨论那些由于文本模糊不清导致法官必须从事更新工作的疑难案件(hard cases),这是法律教授们的职业通病,这些法律教授们总是对大量更为常见的简单案件视而不见,反而总是过多地把目光集中到那些很少发生的,却很吸引人的疑难案件上。”^⑧如果这一判断能够成立,则至少相对而言,德沃金的司法理论比哈特的更为可取(因为前者始终面对的是非典型案件但哈特主要面对的是典型案件),而哈耶克(F. Hayek)的如下判断则多少有点儿天真:“正是那些绝不会诉诸法院的纠纷,而不是那些诉之于法院的案件(也即典型案件——引者注),才是评估法律确定性的尺度”,“现代夸大法律不确定性的趋势,乃是反法治运动的一部分。”^⑨

第三,在法治实践来中,人们应当摒弃机械、二元地看待非典型案件与典型案件或疑难案件与简易案件的观念。更进一步讲,应废止、重构那些初衷是用来专门针对非典型案件(疑难案件)或典型案件(简易案件)的制度安排或实践做法——其中尤其重要的是,应当把认定一个案件是非典型案件(疑难案件、复杂案件)或典型案件(简易案件)的主导权留待诉讼各造行使,而非像现在这样由法院决断;或至少,应当把相应的机制做得更加灵活,进而使得它们在分别处理非典型案件和典型案件时更加容易互相打通。^⑩

另一种符合本文逻辑且更具可行性的建议是,法院给非典型案件设定级数标准,由主审法官根据该标准对源自当事人选择的非典型案件进行非典型或疑难级别的核定,只有那些达到某种非典型级数的案件才可进入相应的特别程序。之所以认为这一建议更具有可行性,是因为它并不需要完全废止或重构当前通行的一些做法,而只需嵌入“非典型定级制度”就可以“重新上路”。当然,如果采行这一建议,则必须坚守的一点是,只有诉讼各造认为适用法律有争议的案件才可能进入定级程序,法官或法院本身无权主动启动这一程序,否则此种建议的实践很可能导致重回现行做法的老路上。

⑧ [美]沃缪勒(Adrian Vermeule):《不确定状态下的裁判:法律解释的制度理论》,梁迎修、孟庆友译,北京大学出版社2011年版,第48页。

⑨ [英]哈耶克:《自由秩序原理》(上卷),邓正来译,三联书店1997年版,第265页。

⑩ 此处或有必要提及的是,当前的这种二分式制度安排还将导致如下问题:如果说一个案件是否属于“本辖区重大案件”或许能够在诉讼展开之前就予以确定的话——之所以是“或许”,是因为对涉诉案件(尤其是刑事案件)而言,只要未经法院审理都不应被轻易定性,那么,一个案件是否属于“本辖区复杂案件”就必定需要经过审理之后方能得出结论。换言之,这一规定在实践中存在操作上的逻辑困难(当然,这种逻辑问题由于申请制度以及移交制度的存在,可以得到某种程度的缓解),并且更恶劣的后果是“鼓励”、至少是助长未审先判的危险司法风气。同样地,对简易程序的规定亦可作如是观相对应地,由于简易案件审理过程中可以、可能转入到普通程序,这个逻辑问题在一定程度也可以得到缓解。但从司法实践来看,简易程序转化为普通程序的比例似乎并不甚高。

Abstract: Atypical case is a hot topic in contemporary legal practice and legal research, and it usually refers to the controversial cases in application of law. From logic aspect, simple suspect fact affirmation with clear and certain disposition does not necessarily lead to atypical case. The indirect reasons of atypical case involve law, fact, the relationship of law and fact, and many other aspects, but the direct reason lies in the choice of the client and law server; as such, atypical case and typical case cannot be divided into two parts, on the contrary, they can transform into the other, which means there exist fundamental defect in system arrangement or practical activities of atypical case, thus the cases must be abolished or reconstructed.

(责任编辑:李小明)